

1502787-54.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O

tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502787-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502787-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2031996/2022 - 35º D.P.

JABAQUARA, 22810051 - 35º D.P. JABAQUARA, 297/22/235 - 35º D.P. JABAQUARA, 2031996 - 35º D.P. JABAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO ADRIANO MOREIRA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

RICARDO ADRIANO MOREIRA DA COSTA, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Isso porque, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta

das 12h45min, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), na Rua Maria Luisa do Espírito Santo, nº 253, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca da Capital, RICARDO ADRIANO MOREIRA DA COSTA, trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 101 (cento e um) porções de cocaína na forma de K2, pesando 24,4 g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas), e 70 (setenta) porções de cocaína, pesando 22,9 g (vinte e dois gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 21 e laudo de constatação de fls. 24/26).

Segundo o apurado, nas circunstâncias referidas, policiais civis, a bordo de viatura descaracterizada, dirigiram-se ao local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, e visualizaram RICARDO ADRIANO MOREIRA DA COSTA carregando uma pochete nas mãos e realizando o comércio de entorpecentes, pois, o denunciado entregou algo a uma pessoa e recebeu dinheiro em troca. Assim, os agentes da Lei decidira abordar o investigado.

Com efeito, o averiguado percebeu a aproximação dos policiais, momento em que RICARDO ADRIANO MOREIRA DA COSTA correu carregando a referida bolsa, entretanto, logo foi detido. Os policiais localizaram, no interior da pochete que ele trazia consigo, 101 (cento e uma) porções da droga K2 e 70 (setenta) porções de cocaína, além de R\$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie.

RICARDO ADRIANO MOREIRA DA COSTA confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 11). As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do denunciado, que culminou com a apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes, acompanhada de certa quantia em espécie, além da confissão em solo policial, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia (fls.1/3), foi ela recebida no dia 05 de maio de 2022 (fls.118). Consequentemente o acusado foi citado (fls.119), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.116/117), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 2022, às 15:00 horas (fls.118), na modalidade presencial.

Durante a instrução da causa foram ouvidos duas testemunhas arroladas na denuncia e o réu, revel, não pode ser interrogado. Anoto que o acusado chegou cerca de 35 minutos atrasado e ao chegar a instrução já havia se encerrado e o feito julgado como constou na ata..

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denuncia. Não se opôs a concessão do redutor em seu percentual máximo., previsto pelo paragrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A Defesa entendeu pela grave divergência entre o teor dos laudos toxicológicos e os depoimentos dos policiais, não se pode dizer que há prova da materialidade delitiva, sendo a absolvição a medida de rigor (art. 386, inc. III, do CPP).

Subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria, fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis. Na etapa intermediária, o réu é primário. Na derradeira fase, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, uma vez que o réu é primário, não ostenta maus antecedentes e não há qualquer indício de que ele tenha envolvimento com atividades/organizações criminosas. Por fim, fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, a substituição desta por restritivas de direitos e a garantia do direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade..

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.4); o boletim de ocorrência (fls.6/8); o auto de exibição/apreensão (fls.21); o termo de interrogatório (fls.11); o termo de depoimento (fls.9/10); o auto de qualificação (fls.13); bem como as folhas de antecedentes (fls.30/32;79).

E o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou

perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.21) e dos laudos de constatação provisória (fls.23/26 ), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 136/138 ), com resultados positivos para COCAÍNA

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Policial Carlos Eduardo, na época trabalhava junto ao 35 DP. Recorda-se dos fatos. Os fatos ocorreram na área do Jabaquara próximo a Diadema. Estavam em uma ação contra o tráfico de drogas, com viatura descaracterizada. O local já era conhecido como ponto de venda de drogas. Conseguiram observar um rapaz com uma pochete em atitude de mercancia. Enquanto um entregava algo a um rapaz este entregou dinheiro ao outro. Resolveram abordar e ao se aproximarem dele, ele tentou correr. Correram atrás dele e o detiveram. Com ele encontraram uma pochete com substância conhecida por K2 (maconha sintética que parece orégano) e cocaína, além de 41 reais. Ele confessou que estava vendendo a droga. Já havia efetuado uma prisão ali. Estava so com o parceiro e por isso optaram em abordar o acusado.

Policial Wlesley, também presente, desde 2021 trabalha no 35 DP. Recorda-se dos fatos. Estava com o parceiro e se deslocaram até o local em uma viatura descaracterizada. Ficaram campanando o local por cerca de 10 a 15 minutos. Percebeu um rapaz com uma pochete. Perceberam uma movimentação de mãos de troca de coisas, típica de venda de drogas. Resolveram fazer a abordagem. Ele tentou fugir. Ele não conseguiu e foi preso. Com ele localizou a pochete tinha 70 porções de cocaína e 100 de K2 e uma porção em dinheiro trocado. Ele admitiu informalmente que era para vender e segundo ele foi o meio mais fácil para conseguir subsistência. K2 é uma droga sintética, eles usam orégano e aplicam um componente químico de substâncias alucinógenas. Mas não tem nada a ver com cocaína.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (Resp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

O réu é revel mas confessou o crime em sede policial. Sua confissão, não invalidada por argumentos solidos da defesa, não pode ser desconsiderada apenas porque foi feita em solo policial, mesmo porque, anoto, a confissão extrajudicial está em total harmonia com o que foi dito pelos policiais civis que o prenderam em

flagrante.

Por fim, quanto a materialidade do crime, afasto a alegação defensiva porque o que comprova a natureza ilícita da substância apreendida são as conclusões lançadas nos laudos periciais oficiais. No caso concreto, ambos os laudos atestaram como cocaína as substâncias apreendidas.

Em momento algum mencionaram tratar-se de K2, como foi dito pelos policiais civis que apenas declararam que uma das substâncias apreendidas aparentava ser K2, conforme constou em suas declarações de fls. 9 e 10.

Eles repetiram isso em juízo, e isso não se pode negar.

Contudo, como já deixei claro, o que prova a materialidade do crime é a prova pericial e não a impressão do policial.

Os dois laudos periciais estão em absoluta harmonia e coincidentes os seus números, tanto o preliminar como o complementar, fls. 23/26 e 136/138. Os dois laudos concluíram que o entorpecente apreendido, em sua totalidade, era cocaína.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante atinente a calamidade pública eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua prática. Não há prova denexo causal entre os fatos.

Em terceira fase, nos termos das ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls. 81. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do

art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno RICARDO ADRIANO MOREIRA DA COSTA, nascido em 18/02/1997, natural de São Roque - SP, filho de Ricardo Moreira da Costa e Marcia Adriana de Oliveira, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão, REGIME ABERTO, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA